



Roj: **STS 5555/2025 - ECLI:ES:TS:2025:5555**

Id Cendoj: **28079130022025100308**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **04/12/2025**

Nº de Recurso: **5789/2023**

Nº de Resolución: **1581/2025**

Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**

Ponente: **SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAN 2870/2023,**
ATS 9252/2024,
STS 5555/2025

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1.581/2025

Fecha de sentencia: 04/12/2025

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 5789/2023

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 21/10/2025

Ponente: Excm. Sra. D.^a Sandra María González de Lara Mingo

Procedencia: AUD.NACIONAL SALA C/A. SECCION 2

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

Transcrito por: RMG

Nota:

R. CASACION núm.: 5789/2023

Ponente: Excm. Sra. D.^a Sandra María González de Lara Mingo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1581/2025

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Francisco José Navarro Sanchís, presidente

D. Isaac Merino Jara

D.^a Esperanza Córdoba Castroverde

D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

D.^a Sandra María González de Lara Mingo

D.^a María Dolores Rivera Frade

En Madrid, a 4 de diciembre de 2025.

Esta Sala ha visto constituida en su Sección Segunda por los Excmos. Sres. Magistrados y las Excmas. Sras. Magistradas indicados al margen, el recurso de casación núm. 5789/2023, interpuesto por el abogado del Estado en representación y defensa de la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada el 10 de mayo de 2023 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento ordinario núm. 701/2019.

Ha comparecido como recurrida la entidad alemana Cosmos Lebensversicherungs, A.G. representada por la procuradora doña Belén Montalvo Soto, y asistido del letrado don Jorge Moreira Peláez.

Ha sido ponente la Excm. Sra. D.^a Sandra María González de Lara Mingo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Resolución recurrida en casación.

Este recurso de casación tiene por objeto la sentencia dictada el 10 de mayo de 2023 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento ordinario núm. 701/2019.

La sentencia aquí recurrida tiene una parte dispositiva del siguiente tenor literal:

«[...] ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora D.^a Belén Montalvo Soto, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 11 de junio de 2019, a que las presentes actuaciones se contraen, la cual anulamos por no ser ajustada a Derecho, en los términos que se infieren del precedente Fundamento Jurídico nº 6, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

Con imposición de costas a la Administración demandada».

SEGUNDO.- Preparación del recurso de casación.

1.El abogado del Estado en representación y defensa de la Administración General del Estado mediante escrito de 17 de julio de 2023 preparó recurso de casación contra la expresada sentencia de 10 de mayo de 2023.

Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identificó como normas infringidas el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR), en relación con el artículo 38 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP). Así mismo, considera vulnerada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2015 [Asuntos acumulados C-10/14, C-14/14 y C-17/14, J.B.G.T. Miljoen y otros c. Staatssecretaris van Financiën (EU:C:2015:608)].

2.La Sala *a quo*, tuvo por preparado el recurso de casación por medio de auto de 21 de julio de 2023, habiendo comparecido el abogado del Estado en representación y defensa de la Administración General del Estado, - como parte recurrente-, ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dentro del plazo de 15 días señalado en el artículo 89.5 LJCA.

De igual modo lo ha hecho como parte recurrida la entidad alemana Cosmos Lebensversicherungs, A.G. representada por la procuradora doña Belén Montalvo Soto, y asistido del letrado don Jorge Moreira Peláez.

TERCERO.- Admisión del recurso de casación.

1.La Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en auto de 10 de julio de 2024, consideró que concurría interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, en virtud del artículo 88.2.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [«LJCA»], en la cuestión jurídica consistente en:

«[...] Determinar si las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que solamente llevan a cabo en España inversiones de carácter financiero, de las que obtienen rendimientos de

capital mobiliario sin establecimiento permanente, puede considerarse, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 del TRLIRNR, por remisión a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) pueden deducirse por estar relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España».

CUARTO.- Interposición del recurso de casación (síntesis de los argumentos del abogado del Estado).

El abogado del Estado en representación y defensa de la Administración General del Estado, interpuso recurso de casación mediante escrito de 20 de septiembre de 2024, que observa los requisitos legales y en el que se mencionan como normas jurídicas infringidas las que han quedado citadas más arriba.

Pretende la recurrente la casación de la sentencia recurrida por cuanto, a su juicio, es contraria a derecho, aduciendo en apoyo de dicha pretensión y en esencia, un extenso relato de los hechos que resultan del expediente administrativo, a continuación, explica que en el artículo art. 24.6 LIRNR la deducción de un gasto se condiciona a que se cumplan dos requisitos (i) que el gasto tenga "un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España", y que, (ii) que el gasto esté "relacionado directamente" con los rendimientos obtenidos en España.

En opinión del abogado del Estado parece claro que son dos requisitos diferentes. Puede que se dé uno, los dos o ninguno.

Afirma que la Sentencia aprecia que cuando se trata de una provisión asimilable a la de participación en beneficios o para extornos del art. 38 del ROSSP, se dan los dos requisitos.

Sostiene la abogacía del Estado que no se da ninguno de los dos requisitos estructurando su razonamiento en dos apartados:

1. En relación con el vínculo económico directo e indisoluble de la provisión técnica con la actividad realizada en España.

Indica que la dotación a la provisión técnica de participación en beneficios o para extornos del artículo 38 del ROSSP -o una similar, equivalente o comparable, como hay que admitir que era el caso- es un gasto propio de la actividad aseguradora, realmente característico de ésta.

Destaca que de hecho, el artículo 13.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, disponía que serán deducibles los "gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras" (lo mismo en el hoy vigente artículo 14.7 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre). Si una provisión similar la efectuara una entidad no aseguradora (hipótesis que, por lo demás, hay que descartar), esa provisión no sería deducible.

Expone que la razón por la que la sentencia considera que este requisito sí concurre en el caso no reside en que la Aseguradora sea, en efecto, una entidad aseguradora en Alemania. Este mero hecho, que es indiscutible, sería irrelevante pues lo que la ley exige es que el gasto tenga un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España. La Abogacía del Estado acepta que esa provisión tiene un vínculo de esa naturaleza con la actividad realizada por la Aseguradora en Alemania y, acaso, en otras jurisdicciones. Pero de lo que se trata es de que lo tenga con la actividad desarrollada en España. Lo que la Sentencia afirma es que la actividad de la Aseguradora en España es una actividad aseguradora (de modo que un gasto característico de ésta es deducible) porque "una concreta inversión financiera, una colocación de capital (...) es parte sustancial de la actividad aseguradora que debe realizar actividades de inversión". La única motivación de este aserto es que (i) "la normativa sobre Ordenación y supervisión de seguros controla la inversión de las entidades aseguradoras", y (ii) no es aceptable "constreñir prácticamente la actividad aseguradora a la asunción de primar a cambio de asumir riesgos" (sic), (iii) "la STS de 5 de junio de 2018 (rec. 634/2017), que en un supuesto de retención de dividendos -no de actividad aseguradora en los términos restrictivos utilizados por el TEAC- entendió que si procedía deducir los gastos".

Cree la Administración que la sentencia yerra al considerar que la actividad desarrollada en España por la aseguradora es una actividad aseguradora. Si no lo es, un gasto característico de las aseguradoras no puede tener el requerido vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

Afirma que:

a) En relación con el concepto de actividad aseguradora está regulada en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (la "Directiva") y, en lo que respecta a los períodos concernidos, el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados,

aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (la "LOSP") o, en cuanto al Derecho hoy vigente, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

La mera inversión en activos financieros -que es la única actividad en España- pueda caracterizarse como actividad aseguradora.

Sostiene que la esencia de la actividad aseguradora es hacerse responsable de las consecuencias lesivas de un evento futuro e incierto (un siniestro) a cambio de una cierta contraprestación dineraria (la prima), de modo que quien puede sufrir, o no, el siniestro traslada a la aseguradora la incierta carga de dichas consecuencias.

b) Régimen de libre prestación de servicios de aseguradora en el España domiciliadas en otros países miembros del Espacio Económico Europeo.

Tras citar y reproducir los artículos 78, 85 y 86 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, señala que las libertades comunitarias permiten que una aseguradora de un Estado miembro desarrolle su actividad en otro sin necesidad de ser residente en éste; puede hacerlo mediante una sucursal, pero ni siquiera es necesario que establezca una sucursal sino que puede actuar directamente desde su Estado de residencia: en esto consiste el "régimen de libre prestación de servicios".

No hay duda de que la Aseguradora no se sujetó a estas normas en absoluto. Y no lo hizo porque ni pretendía operar en España, ni de hecho operó en España como tal entidad aseguradora. Solo pretendía invertir en acciones emitidas por sociedades españolas, para lo que no necesitaba sujetarse a régimen administrativo alguno aplicable al ejercicio en España de la actividad aseguradora.

c) La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2018 (Rec. 634/2017) no es aplicable al caso, ya que aplica e interpreta una norma distinta y además versaba sobre contratos denominados "unit linked", "caracterizados por una nota común: que el tomador del seguro asume el riesgo de la inversión".

2. En cuanto a relación directa de la provisión técnica con los rendimientos obtenidos en España.

El abogado del Estado sostiene que de ningún modo la existencia de tal relación directa es "un problema de gestión y de prueba" (como interpreta la sentencia), ni tal cosa es la que entendió la resolución del TEAC.

Precisa que se trata de una cuestión jurídica, de interpretación de la norma -el artículo 24.6- respecto del caso de la provisión técnica "de participación en beneficios y para extornos" del artículo 38 del ROSSP, al que según parece se asimilan las provisiones alemanas que la sentencia considera deducibles del IRNR.

Expone que en diversas resoluciones, el TEAC viene proporcionando respecto de este punto una motivación impecable. Entre otras cosas, dice que «no existe una relación entre el riesgo asumido por cada tomador y unos activos específicamente afectos al mismo, por lo que no puede afirmarse que los dividendos cobrados en territorio español hayan determinado (...) una mayor dotación de la provisión del artículo 38 que el reclamante pretende deducible». Es decir, sencillamente no hay relación -menos aun directa- entre la dotación a la provisión y los dividendos percibidos de sociedades españolas. La inexistencia de una relación directa no se afirma sobre la base de concluir sobre los hechos mediante la valoración de pruebas sino sobre la del análisis conceptual de la provisión de que se trata, de su naturaleza.

En palabras del abogado del Estado la cuestión no es si hay o no alguna relación sino si esa hipotética relación es directa. Pues si hubiera una relación pero no directa, entonces la recta aplicación del artículo 24.6 proscibiría la deducción de la provisión. La Sentencia cree que pasa completamente por alto la naturaleza directa que necesita tener la relación entre el gasto que se quiere deducir y los dividendos. Si la relación, aun existiendo, es indirecta, mediata, no biunívoca, entonces no procede la deducción.

Tras reproducir el artículo 38 ROSSP afirma que lo que es decisivo es la expresión de lo que constituye la causa del derecho que ciertos contratos de seguro reconocen al tomador, asegurado o beneficiario: «en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de aquéllos». De modo que el vínculo no se establece entre la provisión (cuya dotación es deducible) y tales o cuales rentas (las rentas, ingresos o inversiones no se toman en consideración para nada: no guardan relación con esta provisión) sino entre la provisión y la evolución del riesgo. En efecto, algunos contratos de seguro contemplan el derecho a recuperar parte de la prima satisfecha si al cabo de determinado período, por ejemplo el periodo del seguro, se ha producido un superávit de la cuenta de resultados de la póliza; o, en otras palabras, si la siniestralidad ha resultado favorable.

Indica que la ausencia de toda relación directa entre este tipo de provisiones y los dividendos se comprende todavía mejor, si cabe, contrastándolo con la llamada "Provisión de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión", a la que se refiere el artículo anterior, el 37 del ROSSP que reproduce.

En los llamados seguros "unit linked", en realidad una operación de inversión más que de seguro, si bien que se realiza por entidades aseguradoras bajo la veste formal del contrato de seguro. Las características son las contrarias: a) No guarda relación con la evolución del riesgo. b) Corresponde a contratos en que se ha "estipulado que el riesgo de inversión será soportado íntegramente por el tomador" (no es la entidad aseguradora, como es propio del genuino seguro, la que asume el riesgo de la ocurrencia de un siniestro). c) Y la provisión (el gasto deducible) sí se "determinará en función de los activos específicamente afectos o de los índices o activos que se hayan fijado como referencia". De modo que entre los dividendos obtenidos por tales activos y la provisión sí hay una relación directa.

Termina suplicando a la Sala:

«[...] Las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que no tienen en España establecimiento permanente ni actúan en régimen de libre prestación de servicios y solamente llevan a cabo en España la actividad de realizar inversiones de carácter financiero, de las que obtienen rendimientos de capital mobiliario, no tienen, en aplicación del artículo 24.6 del TRLIRNR, el derecho a deducir de la base imponible del IRNR los gastos relativos a las provisiones técnicas comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP, exclusivas de la actividad aseguradora, porque no están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España ni tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España».

QUINTO.- Oposición al recurso de casación (síntesis de los argumentos de la parte recurrida).

La entidad alemana Cosmos Lebensversicherungs, A.G. representada por la procuradora D.^a Belén Montalvo Soto, y asistido del letrado D. Jorge Moreira Peláez, presentó escrito de oposición el 29 de octubre de 2024.

Para fundamentar la desestimación del recurso de casación estructura su defensa en dos apartados.

1. En el primer apartado denuncia que el presente recurso plantea un debate jurídico impostado, toda vez que, como reconoce el propio recurrente, el precepto que se dice principalmente infringido no estaba en vigor en los períodos en los que se pretende aplicar (los años 2010 a 2012), sino también porque, en la hipótesis de que se admita que el artículo retrotrajo su vigencia, la infracción de él atribuida a la sentencia recurrida no habría sido tal y, si lo hubiera sido, justificaría que esa Sala, como ya hizo la de instancia, considerase que el entonces infringido artículo 24.6 resultaría -y sigue resultando contrario a la normativa comunitaria, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE"), o dicho de otro modo, que su promulgación fue infructuosa en el objetivo de adaptar el ordenamiento jurídico español a esa misma jurisprudencia, pues no habría evitado una discriminación injustificada.

2. El segundo apartado lo destina a tratar sobre la correcta aplicación e interpretación del artículo 24.6 de la LIRNR y sobre la regulación de la provisión para participación en beneficios financieros.

Expone que Cosmos Lebensversicherungs, A.G. es una entidad aseguradora alemana que en los ejercicios 2010 a 2012 percibió dividendos con cargo a distintas participaciones accionariales mantenidas en sociedades españolas cotizadas. Ni en aquel entonces, ni ahora, mantenía en España una presencia con el carácter o no de establecimiento permanente a través del que hiciera esas inversiones o desarrollase cualquier otro tipo de actividad en nuestro país.

Afirma que como consecuencia de ello, y de conformidad con el artículo 15.1, segundo párrafo, de la LIRNR, cada uno de los rendimientos en concepto de dividendos que percibió en cada uno de los años 2010 a 2012 fue objeto de imposición de forma independiente entre sí y con respecto a los posibles rendimientos de cualquier otra naturaleza que pudo haber obtenido en dichos ejercicios.

En esos períodos, esta tributación tenía el carácter de definitiva de acuerdo con el diseño normativo de la LIRNR que impedía la deducción de gastos, lo que constituía una discriminación de las entidades no residentes frente a las entidades residentes que el TJUE ya había empezado a reconocer en varios pronunciamientos.

Dice que consciente del agravio comparativo del que era víctima decidió ejercer su derecho de tributar del mismo modo que lo habría hecho una entidad aseguradora española que hubiera percibido los mismos dividendos y asignado del mismo modo una parte de ellos a sus clientes, tomadores y beneficiarios de contratos de seguro de vida-ahorro, mediante la dotación de la misma provisión para participación en beneficios financieros que Cosmos en favor de los suyos, lo cual llevó a efecto solicitando la devolución de la parte de las retenciones soportadas que se correspondía con la diferencia entre la renta bruta percibida, esto es, los dividendos, y la renta neta por la que tiene sentido que tributase en España considerando que el

artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce y garantiza la libre circulación de capitales, es decir, la renta neta por la que habría tributado esa entidad aseguradora española que estuviera en su misma posición.

Destaca que frente al parecer de la sentencia recurrida, la representación del Estado considera, en cambio, que Cosmos no podía ejercer el citado derecho en los términos expresados por ella, lo cual pretende justificar en una aplicación retroactiva de la versión de 2014 del artículo 24.6 de la LIRNR conforme a una interpretación inaudita de este precepto que excluye a Cosmos de su supuesto de hecho.

Argumenta que en lo que respecta a los ejercicios 2010 a 2012, el alcance del derecho del recurrido no puede venir determinado por el artículo 24.6 de la LIRNR, sino por el artículo 63 del TFUE en la interpretación dada al mismo por el TJUE.

Sostiene que, sin perjuicio de lo anterior, si a efectos dialécticos se admitiera que la versión de 2014 del artículo 24.6 de la LIRNR contiene el "canon" de lo que constituye un trato igualitario, a mayor abundamiento también considera que el recurso debe ser rechazado por cuanto que la interpretación de esta norma que sostiene la Abogacía del Estado es claramente infundada y contraria a su propia literalidad.

Indica que los artículos 7.7 y 10.5 del Convenio, en relación con los artículos 7.1 y 10.2, determinaban que los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante (en este caso, España) a una empresa del otro Estado Contratante (en este caso Cosmos) podían excepcionalmente someterse a tributación en nuestro país pese a constituir un beneficio empresarial obtenido sin la mediación de un establecimiento permanente, tipo de renta naturalmente exenta de tributación en el marco de los convenios acomodados al modelo de la OCDE.

Afirma que aceptar lo que propone el abogado del Estado sería tanto como asumir que el artículo 24.6 de la LIRNR solo vino a garantizar el respeto de la libre prestación de servicios aseguradores por el ordenamiento español -el derecho de establecimiento a través de filial o de sucursal no se ve concernido en absoluto en este caso-, cuando lo que vino a garantizar fue no solo esa libertad empresarial, sino principalmente la libre circulación de capitales habida cuenta del ámbito efectivo de aplicación del precepto, tal como se vino a reconocer en el preámbulo de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, mediante la que se reformó la previa redacción de dicho precepto.

Reconoce que como dice la parte recurrente, la inversión en acciones de entidades españolas no comporta en sentido estricto el ejercicio de la actividad aseguradora en nuestro país, pero no es menos cierto que, cuando, como en el caso de Cosmos, se trata del ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de vida y, más concretamente, de la comercialización de productos de seguro que cumplen la función de canalización del ahorro financiero de los tomadores (i.e. frente a los que cubren el puro riesgo de sobrevivir o fallecer), la actividad de inversión de los fondos allegados a modo de primas o aportaciones forma parte de la actividad aseguradora en sentido amplio, máxime si, como es el caso de los seguros con participación en beneficios financieros o de los seguros unit-linked, tal inversión redunda directamente en beneficio de los mencionados tomadores.

Argumenta que, la tesis de la parte contraria, llevada a sus últimas consecuencias, daría lugar a entender que las compañías de seguros españolas sólo pueden deducir en su IS las dotaciones a las provisiones técnicas asociadas a inversiones emitidas por entidades españolas cuando los contratos a los que están vinculadas hayan sido celebrados en España, lo cual no es por supuesto lo que dice el artículo 14.7 de la LIS.

Denuncia que el abogado del Estado en su escrito omite que la provisión para participación en beneficios es una provisión técnica que puede referirse a los beneficios financieros, y no solo a los técnicos, tal y como reconoce implícitamente el artículo 38 del ROSSP.

Señala que las dotaciones a la provisión técnica para participación en beneficios financieros (en concreto, entre otros, en los dividendos distribuidos por entidades españolas) que registró Cosmos en todos esos años pertenecen a la tipología de provisiones dotación para participación en beneficios financieros pues su finalidad era representar contablemente la obligación legal y estatutaria que tenía de asignar o atribuir, mediante la dotación de esa provisión, una buena parte del valor de esos rendimientos financieros -el 90 % como mínimo- como mayor valor de los derechos económicos (i.e. derecho de rescate y derecho al cobro de una prestación) a los tomadores de las pólizas de seguro de vida-ahorro contratadas con ella con arreglo a lo establecido en dichos contratos y la legislación que los regulaba.

Dice que a esta conclusión no obsta la jurisprudencia del TJUE citada por la contraparte, sino que la refuerza. De hecho, no se alcanza a entender la razón por la que afirma el abogado del Estado que esta jurisprudencia, concretada en la sentencia de 17 de diciembre de 2015 (Société Générale SA, Asunto C-17/14), avala la infracción del artículo 24.6 de la LIRNR por la sentencia de instancia. Al contrario, esta jurisprudencia corrobora

que la tesis de la representación del Estado de que es necesario que el no residente ejerza la actividad aseguradora en España es equivocada, pues basta con que el gasto en cuestión esté directamente relacionado con la percepción de los dividendos gravados, como es el caso de la provisión discutida. Más aún, la jurisprudencia contenida en la STS de 5 de junio de 2018 (rec. cas. n.º 634/2017) también concuerda, aunque se refiera a la provisión dotada para asignar dividendos a los tomadores de seguros unit-linked, con la pretensión casacional de la entidad recurrida.

SEXTO.- Deliberación, votación y fallo del recurso.

De conformidad con el artículo 92.6 de la LJCA, y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia de 4 de noviembre de 2025, quedó el recurso concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo.

Por providencia de 19 de septiembre de 2025, se designó ponente a la Excm. Sra. D^a. Sandra María González de Lara Mingo y se señaló para la deliberación, votación y fallo del recurso el 21 de octubre de 2025, fecha en que comenzó la deliberación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en determinar si las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que solamente llevan a cabo en España inversiones de carácter financiero, de las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, puede considerarse, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 del TRLIRNR, por remisión a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) pueden deducirse por estar relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.

SEGUNDO.- Hechos relevantes para la resolución del recurso de casación.

Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como datos relevantes para la resolución del recurso de casación los siguientes:

1. Retenciones soportadas por el Cosmos Lebensversicherungs, A.G. como consecuencia de las inversiones realizadas en España durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Cosmos Lebensversicherungs, A.G. es una entidad aseguradora residente fiscal en Alemania incluida en el ámbito de aplicación de las Directivas 2002/83/CE y 91/674/C.

A los efectos de determinar su resultado contable aplica la legislación alemana.

Cosmos Lebensversicherungs, A.G., percibió durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012 dividendos procedentes de diversas entidades españolas, en relación con los cuales soportó una retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes ("IRNR") equivalente al 15% del importe bruto de dichos dividendos, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes ("LIRNR"), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 10 del Convenio Hispano-Alemán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.

Los pagadores fueron Banco Santander, S.A., Repsol YPF, S.A., Iberdrola, S.A., Telefónica, S.A., Inditex, S.A., Banco Sabadell, S.A., Abertis, S.A., Red Eléctrica, S.A., Banco Popular, S.A. y BBVA, S.A.

2. Solicitud de devolución de las retenciones soportadas derivadas de la percepción de dividendos en España.

Cosmos Lebensversicherungs, A.G. solicitó a la AEAT, dentro del plazo preceptivo, mediante la presentación de las declaraciones, modelo 210, correspondientes a las rentas obtenidas por no residentes sin establecimiento permanente que le afectan, la devolución de las retenciones excesivas que había soportado en aplicación de una norma incompatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE), que exigía la aplicación de un tipo impositivo del 15% aplicado sobre el importe bruto de los dividendos recibidos -base imponible bruta- en lugar de sobre la base imponible neta una vez deducidos los gastos vinculados con la obtención de dicha renta, en el presente caso consistente en la provisión técnica dotada por la entidad, y que resultaría deducible en el caso de un contribuyente español que se encontrara en las mismas circunstancias.

3. Tramitación de las solicitudes de devolución de ingresos indebidos.

Dentro de la tramitación de cada una de las citadas solicitudes de devolución, la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la AEAT de Madrid, remitió a la solicitante otras tantas propuestas de liquidación con las que inició por los correspondientes procedimientos de comprobación limitada.

En el plazo conferido, la entidad presentó alegaciones a la propuesta de liquidación provisional. Puede leerse en alguna de esas propuestas que son todas de similar contenido que:

«Dicho lo anterior, en primer lugar, interesa a esta parte poner de manifiesto ante esa Administración que, a los efectos de acreditar los datos consignados en la declaración para la **determinación del importe de la base imponible**, ésta se ha calculado de la siguiente manera:

- En primer lugar se ha partido del **importe bruto de los dividendos recibidos**. Dicho importe se acredita a través del certificado del banco custodio (Commerzbank AG) que se adjunta como Anexo III a este escrito, así como de los certificados del banco subcustodio (Banco Santander) que se aportan como Anexo IV a este escrito.

- A continuación, de dicho importe bruto se **ha deducido la dotación a la provisión de participación en beneficios aplicada por su representada** (provisión técnica).

Pues bien, en relación con este segundo extremo, interesa a esta parte poner en conocimiento de esa Administración que la normativa alemana de aplicación a estos efectos, a saber la "Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung" (también conocido como Mindestzuführungsverordnung o MindZV), reconoce un porcentaje de provisión técnica del 90 por ciento. A estos efectos, se aporta como Anexo V a este escrito tanto el texto completo de la norma en lengua alemana como la traducción al inglés de los extractos de dicha norma en los que se acredita el dictado porcentaje de provisión técnica.

Ahora bien, conviene precisar que, tal y como se extrae del apartado 4 del MindZV, dicho porcentaje actúa como un límite mínimo, esto es, cada entidad como mínimo puede dotar una provisión técnica del 90 por ciento, sin perjuicio de que las entidades aseguradoras amparadas por el ámbito subjetivo de la citada normativa apliquen un porcentaje de provisión técnica superior, como sería el caso de su representada.

Concretamente, para el año 2010 su representada dotó una provisión técnica del 95,10%, que sirvió de base a esta parte para el cálculo de la deducción aplicada para la determinación de la base imponible declarada en el modelo 210 presentado. A estos efectos, se aporta como Anexo VI a este escrito copia de la traducción jurada del extracto de las cuentas anuales de la entidad en la que figura el porcentaje de provisión técnica dotada que ha sido señalado con anterioridad».

La Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, dictó 15 liquidaciones provisionales como consecuencia de diversas solicitudes de devolución del Impuesto sobre la Renta de No Residentes sin establecimiento permanente: Números de referencia AEAT: 200921004800719L, 200921004800721M, 200921004800717N, 200921004800712Y, 200921004800709M, 200921004800710E, 200921004800705Z, 200921004800711Z, 200921004800708J, 200921004800707K, 201021004800085W, 201021004800083H, 201021004800082A, 201121049220189A, 201221049220086H.

Las liquidaciones razonaron de la siguiente manera:

«El contribuyente en las alegaciones presentadas hace destacar que se trata de una compañía aseguradora residente en la Unión Europea que pretende, en aplicación del principio de no discriminación y libre circulación de capitales, **la deducibilidad de la dotación a las provisiones técnicas de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de no Residentes**, que en este caso está constituida por los ingresos obtenidos por dividendos procedentes de entidades españolas. Las provisiones técnicas para el caso de las entidades residentes en territorio español y en aplicación del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2004 vigente en la fecha de devengo del Impuesto sobre la Renta de No Residentes objeto de autoliquidación en el correspondiente modelo 210 de referencia, serán deducibles para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas en las normas aplicables».

4. Interposición de reclamación económico-administrativa.

Contra los acuerdos de liquidación Cosmos Lebensversicherungs, A.G interpuso las reclamaciones económico-administrativas núm. 00-00604-2016; 00-00605-2016; 00-05278-2016; 00-06491-2016; 00-06696-2016; 00-00932-2017 ante el Tribunal Económico- Administrativo Central.

El 11 de junio de 2019 el Tribunal Regional dictó resolución por la que desestimó las citadas reclamaciones acumuladas.

En dicha resolución se indicó que:

«Ahora bien, en el cálculo y dotación de dicha provisión [artículo 38], y a diferencia de la prevista en el artículo 37 del mismo texto legal, no existe una relación entre el riesgo asumido por cada tomador y unos activos específicamente afectos al mismo, por lo que no puede afirmarse que los dividendos cobrados en territorio español hayan determinado, como sí sucede en la provisión del artículo 37, una mayor dotación de la provisión del artículo 38 que el reclamante pretende deducible.

Al no existir esta relación, no cabe otorgar el carácter de gasto deducible a la provisión de participación en beneficios y para extornos prevista en el artículo 38 del Real Decreto 2486/1998. No hay manera de conocer si los concretos dividendos obtenidos en España tienen relación con pólizas que obligan a retornar beneficios a los tomadores, o con otro tipo de pólizas. Y, en el primer caso, en qué cuantía.

La norma española permite deducir al no residente en los términos en que la norma interna autoriza al residente, persona física o jurídica según los casos, los gastos directamente relacionados con los rendimientos obtenidos en España y que tengan con estos un vínculo económico directo e indisociable. Exigencia esta lógica y asimilable a la correlación exigida en nuestra normativa interna a los residentes y que en el caso de no residentes sin EP tiene aún mayor razonabilidad, si cabe, toda vez que su actividad en España será indudablemente residual respecto a la ejercida en otras jurisdicciones y resulta esencial delimitar los gastos directa y exclusivamente asociados a sus rendimientos en España. No cumple la provisión del artículo 38 del Real Decreto 2486/1998 que el reclamante pretende gasto deducible dicha exigencia de encontrarse directa y exclusivamente asociada a sus rendimientos en España, y eso es así porque en la misma, a diferencia de la regulada en el artículo precedente del mismo Reglamento, no se identifica individualmente las acciones o títulos cuyos rendimientos han dotado la provisión, por lo que no puede considerarse acreditado que los dividendos obtenidos por el reclamante en territorio español se hayan destinado a dotar la provisión técnica del artículo 38 del Real Decreto 2486/1998, y no a cualquier otro fin o gasto de la entidad aseguradora que no se encuentre directamente relacionada con la actividad que ésta desarrolle en territorio español.

[...]

Pues bien, en el caso que nos ocupa, no se aprecia ninguna discriminación. La reclamante no ha estado sometida a tipo de retención superior a la retención que también han soportado los residentes, el tipo de gravamen que ha aplicado ha sido inferior al que, tras aplicar la deducción por doble imposición de dividendos, habría aplicado una entidad española perceptora de los dividendos, y las diferencias derivadas de la ausencia de gastos deducibles no se producen por la falta de reconocimiento de dichos gastos por la legislación española (legislación que cumple los estándares del TSJUE al exigir que se trate de gastos relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tengan un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España), sino por la falta de prueba adecuada de los mismos, tal y como ya se ha expuesto».

5. Interposición del recurso contencioso-administrativo.

Cosmos Lebensversicherungs, A.G. interpuso recurso contencioso-administrativo contra la mencionada resolución, que se tramitó con el núm. 701/2019 ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La *ratio decidende* de la sentencia sobre este particular se contiene en el Fundamento de Derecho Cuarto y Quinto con el siguiente tenor literal:

«[...] 4. Sobre la vulneración de la libre circulación de capitales.

En cuanto a la cuestión de fondo propiamente dicha, la Sala ha resuelto cuestiones idénticas a las que ahora se nos plantean, además de en la SAN que acabamos de citar de 31 de marzo de 2023, en otra de la misma fecha (recaída en el recurso nº 776/2019), en la de 5 y 10 de mayo de 2023 (recursos nº 883/2019 y nº 884/2019), que siguen el criterio de las otras dos anteriores en procesos todos ellos también seguidos a instancias de aseguradoras alemanas, a propósito de la aplicación del artículo 24 de la LIRNR, sentencias que, a su vez también siguen el criterio expresado ya en la SAN de 28 de octubre de 2016 (R. 13/2013), que se invoca también en la actual demanda y que fue confirmada por la STS de 5 de junio de 2018 (R.C. 634/2017), seguido también en la SAN de 20 de septiembre de 2018 (R. 174/2015), ésta última no recurrida.

En resumen, la Sala viene manteniendo que resulta contrario al Derecho de la UE no permitir la deducción de los gastos a la hora de determinar la base imponible; y así lo ha venido también a entender el propio legislador que permite la deducción de los gastos de las personas jurídicas no residentes sin establecimiento permanente, siempre que exista vinculación directa entre los ingresos obtenidos en España y tales gastos. En este sentido hemos declarado en la SAN de 5 de mayo de 2023 (FJ SEGUNDO):

"Por todas estas razones, en nuestras SAN (2ª) (dos) de 31 de marzo de 2023 (Rec. 736/2019 y 776/2019), en coherencia con el criterio que hemos venido manteniendo, hemos afirmado que admitida por el TS "la deducibilidad de las provisiones anudadas a las pólizas "unit linked",..... no encontramos razón para no aceptar la deducibilidad de las provisiones de las pólizas "no unit linked", si esa posibilidad existe en el ordenamiento español en el Impuesto de Sociedades para las aseguradoras residentes en España, porque, de ser así, se estaría dando un trato diferenciado a situaciones indiferenciadas, contrario al principio de la no discriminación y a la libre circulación de capitales. Obviamente siempre que se acredite la misma vinculación económica directa e indisociable con la actividad realizada en España, es decir, la obtención de dividendos". Como de hecho, salvo error de lectura, ya hicimos en nuestra SAN (2ª) de 20 de septiembre de 2018 (Rec. 174/2015).".

5. Sobre la vinculación de las provisiones técnicas con el ingreso (dividendos obtenidos en España).

Y, en la misma sentencia (FJ TERCERO) después de analizar el significado de las provisiones técnicas en el ámbito del contrato de seguro y su tratamiento fiscal como "gasto deducible", examinamos la cuestión esencial - idéntica, como decíamos, a la que ahora debemos resolver - rechazando los argumentos dados por el TEAC (a los que se remite el Abogado del Estado en su contestación a la demanda) en los siguientes términos:

"Una vez que hemos llegado a la conclusión de que las provisiones son un "gasto" que debe ser tenido en cuenta debemos proceder al examen de lo que, en nuestra opinión, es la cuestión esencial que debe ser objeto de debate. En efecto, en lo esencial esto no es discutido por la demandante, solo podrán deducirse los gastos o si se quiere las provisiones que "están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España".

Al analizar este punto el TEAC sostiene que solo deben tenerse en cuenta los gastos vinculados con "la concreta actividad realizada en el país de la fuente". Rechazando -pp. 14 y ss- el juego de las provisiones del art 38 del RD 2486/1998.

Razona que, por una parte, la actividad "realizada en España" no es la actividad aseguradora sino, tan solo, una concreta inversión financiera, una colocación de capital. En nuestra opinión este argumento no puede acogerse. Lo que en TEAC denomina una "mera colocación de capital" es parte sustancial de la actividad aseguradora que debe realizar actividades de inversión. De hecho, la normativa sobre Ordenación y supervisión de seguros controla la inversión de las entidades aseguradoras. No cabe por ello afirmar que la inversión en determinados activos no constituye una actividad económica realizada en España. Lo que se recoge en los informes aportados -pp.17 y ss. de la Resolución del TEAC- donde se explican las características de los contratos de seguros suscritos, los tomadores y la "forma de determinación del beneficio y la imposición sobre el mismo en base a lo dispuesto en la legislación alemana" y donde puede verse que realiza actividades unit likend y no unit linked, como por lo demás se reconoce en las pp. 6 y 16 de la demanda.

Por otra parte, esta forma de razonar viene a constreñir prácticamente la actividad aseguradora a la asunción de primar a cambio de asumir riesgos, pero al margen de que como hemos razonado que esto no es así, lo anterior se compadece mal con el criterio sostenido en le STS de 5 de junio de 2018 (Rec. 634/2017), que en un supuesto de retención de dividendos -no de actividad aseguradora en los términos restrictivos utilizados por el TEAC entendió que sí procedía deducir los gastos.

Debemos pues analizar el segundo argumento. Sin duda más complejo.

En esencia, lo que viene a sostener el TEAC es que frente a lo que ocurre en las provisiones técnicas de los seguros unit linked, en otros seguros, "no hay manera de conocer si los concretos dividendos obtenidos en España tienen relación con las pólizas que obligan a retornar los beneficios a los tomadores, o con otro tipo de pólizas...y en que cuantía". Se trata de provisiones, se razona, "no concretos del específico rendimiento obtenido en España", por lo que es mejor que su deducibilidad, la cual no se niega, "se haga en el territorio de residencia que es donde la totalidad de circunstancias de la entidad puede conocerse, controlarse y tener el adecuado trato fiscal". Y concluye que la negativa a la deducción no se debe a la falta de reconocimiento de que, en efecto, la provisión técnica es deducible, sino a la "falta adecuada de prueba de los mismos". Admitir la posibilidad de deducción de las provisiones técnicas de participación en beneficios haría que el impuesto fuese de "muy compleja gestión, al exigir tener en cuenta en el estado de la fuente la situación global de la entidad en el país de residencia, situación que no será fijada hasta muchos meses después de liquidar el impuesto".

En resumen, el TEAC termina por admitir, quizás desdiciéndose de sus argumentaciones, que las provisiones técnicas reguladas en el art 37 del RD 2486/1998, es decir, las provisiones de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión, si serían deducibles. Y lo hace por entender, lo cual es cierto, que, conforme se infiere del art. 37, en las provisiones vinculadas a los seguros unit likend, el riesgo de la inversión es soportado "íntegramente por el tomador" y "se determinará en función de los activos específicamente afectos o de los índices o activos que se hayan fijado como referencia para determinar el valor numérico de dichos

derechos". Lo que supone que resulta posible verificar la conexión, pues en esta provisión "la dotación se hace en función de los riesgos de activos específicamente afectos, por lo que cabe establecer una relación directa entre la evolución de dichos activosy el importe que debe dotarse por dicha provisión para hacer frente a las obligaciones asumidas por la entidad con dichos tomadores o asegurados por el riesgo de inversión asumido por los mismos".

En el fondo, por lo tanto, como señala el TEAC se trata de un problema de dificultad en la gestión, pues la vinculación directa es relativamente sencilla de determinar en los casos de las provisiones relativas a los seguros unit linked, pero no lo es respecto de otras provisiones.

(...)

Ahora bien, como hemos razonado en la SAN (2ª) de 31 de marzo de 2023 (Rec.736/2019), "los problemas operativos [o de prueba] que justificaron la denegación del TEAC...no pueden condicionar una respuesta equivalente entre las aseguradoras residentes y no residentes". Dicho de otro modo, la complejidad en la gestión no puede justificar la discriminación." ».

La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

TERCERO.- Criterio de la Sala. Remisión a la sentencia núm. 1.463/2025 de 17 de noviembre de 2025 (rec. de casac. núm. 5786/2023).

Sobre la cuestión planteada en el auto de admisión de este recurso de casación nos hemos pronunciado en la sentencia núm. 1.463/2025 de 17 de noviembre de 2025 (rec. de casac. núm. 5786/2023). Se trata de un recurso seguido entre la AEAT y otra compañía aseguradora alemana en el que se planteaban las mismas cuestiones que en este recurso de casación por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley (artículos 9.3 y 14 de la Constitución), imponen aquí reiterar el criterio interpretativo que allí se siguió y las cuestiones planteadas merecen igual respuesta que la que en aquella sentencia se contiene.

En dicha sentencia decíamos:

«[...] Es necesario interpretar el artículo 24 TRLIRN, relativo a la base imponible en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, que en su redacción aplicable disponía que:

«6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1.ª Para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España [...].»

Dicho precepto fue modificado por el artículo 2.5 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, pasando a tener el siguiente contenido:

«6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1.ª Para la determinación de base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir:

[...] b) En caso de entidades, los gastos deducibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

2.ª La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas previstas en la Sección 4.ª del Capítulo II del Título III y en la Sección 6.ª del Título X salvo el artículo 94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los contribuyentes residentes en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos

previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal».

Según se señala en su Preámbulo, la reforma obedeció a dar una mayor claridad y favorecer las libertades de circulación recogidas en el Derecho de la Unión Europea, a cuyo fin se distingue, para los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, entre personas físicas o personas jurídicas, estableciendo, para cada uno de estos dos supuestos, los gastos deducibles para el cálculo de la base imponible, por remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, respectivamente.

En ese punto conviene recordar que, en su escrito de interposición, la Abogacía del Estado manifiesta que la RTEAC asumió que la aseguradora tenía derecho a deducir los gastos deducibles de acuerdo con la LIRNR, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. Es decir, según la propia Abogacía del Estado, la resolución recurrida no se basó en que las dotaciones a las provisiones no eran deducibles porque con arreglo a la norma vigente en el período relevante solo lo fueran los "gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" sino porque no se cumplían los requisitos de relación directa con los rendimientos obtenidos en España y de vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España; y esto por entender que ya antes de la reforma de 2014 el Derecho de la UE determinaba que, tratándose de personas jurídicas, los gastos deducibles eran los comparables a los propios del Impuesto sobre Sociedades ("IS"). Es decir, que a esta conclusión conducía la interpretación de la ley a la luz del Derecho de la UE y que la ulterior reforma respondía a una necesidad de aclaración más que a una efectiva ampliación de lo deducible.

Por su parte, el artículo 13.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y también el artículo 14.7 de la vigente Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, otorgan la calificación de gasto fiscalmente deducible para la determinación de la base imponible de este impuesto, al que están sometidas las entidades aseguradoras con residencia fiscal en España, a los gastos relativos a las provisiones técnicas, sin distinción entre ellas, hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables.

La redacción de ambos es la misma. Concretamente es la siguiente: *«los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras, serán deducibles hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables. Con ese mismo límite, el importe de la dotación en el ejercicio a la reserva de estabilización será deducible en la determinación de la base imponible, aun cuando no se haya integrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cualquier aplicación de dicha reserva se integrará en la base imponible del período impositivo en el que se produzca.*

Las correcciones por deterioro de primas o cuotas pendientes de cobro serán incompatibles, para los mismos saldos, con la dotación para la cobertura de posibles insolvencias de deudores.».

Por su parte, el artículo 29 (Concepto y enumeración de las provisiones técnicas) del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP), en la redacción a la sazón vigente, establece:

«1. Las provisiones técnicas deberán reflejar en el balance de las entidades aseguradoras el importe de las obligaciones asumidas que se derivan de los contratos de seguros y reaseguros. Se deberán constituir y mantener por un importe suficiente para garantizar, atendiendo a criterios prudentes y razonables, todas las obligaciones derivadas de los referidos contratos, así como para mantener la necesaria estabilidad de la entidad aseguradora frente a oscilaciones aleatorias o cíclicas de la siniestralidad o frente a posibles riesgos especiales. La corrección en la metodología utilizada en el cálculo de las provisiones técnicas y su adecuación a las bases técnicas de la entidad y al comportamiento real de las magnitudes que las definen, serán certificadas por un Actuario de Seguros, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad aseguradora.

En el caso de que se elaboren balances con periodicidad diferente a la anual, el cálculo y la constitución de las provisiones técnicas se efectuarán aplicando los criterios establecidos en este Reglamento con la adaptación temporal necesaria.

2. Las provisiones técnicas son las siguientes:

- a) De primas no consumidas.*
- b) De riesgos en curso.*
- c) De seguros de vida.*

- d) De participación en beneficios y para extornos.
- e) De prestaciones.
- f) La reserva de estabilización.
- g) Del seguro de decesos.
- h) Del seguro de enfermedad.
- i) De desviaciones en las operaciones de capitalización por sorteo.

3. Las provisiones técnicas aplicables al reaseguro aceptado y cedido serán las recogidas en los párrafos a) a e), ambas inclusive, del apartado anterior, exceptuando, en cuanto al cedido, la contemplada en el párrafo b). Igualmente será aplicable la provisión contemplada en el párrafo f) anterior para las aceptaciones en reaseguro de riesgos catastróficos.

El importe correspondiente a las provisiones técnicas del reaseguro aceptado y cedido deberá calcularse en la forma prevista en este Reglamento, teniendo en cuenta, en su caso, las condiciones específicas de los contratos de reaseguro suscritos.

El cálculo de las provisiones por operaciones de reaseguro aceptado, tomará como base los datos que facilite la entidad cedente, incrementándolos en cuanto proceda de acuerdo con la experiencia de la propia entidad.

4. Las entidades exclusivamente reaseguradoras deberán constituir provisiones técnicas, incluida la reserva de estabilización, suficientes para el conjunto de sus actividades.».

El propio RTEAC entendió que la aseguradora pretendía la deducción de la dotación a una provisión que, con independencia de su denominación y régimen en Alemania, resulta equivalente a una de las provisiones técnicas reguladas en el Derecho español aplicable a las entidades aseguradoras residentes, la "provisión de participación en beneficios y para extornos", incluida en la enumeración del art. 29.2 regulada en el art. 38, ambos del ROSSP.

También es necesario interpretar el art. 38 ROSSP, referente a la provisión de participación en beneficios y para extornos, que determina que:

«1. Esta provisión recogerá el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o beneficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados, en su caso, en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de aquéllos.

2. Los seguros distintos del seguro de vida que garanticen el reembolso de primas bajo determinadas condiciones o prestaciones asimilables incluirán en esta provisión las obligaciones correspondientes a dicha garantía, calculadas conforme a las siguientes normas:

Se incluirán en la provisión todas las obligaciones por los contratos que sobre la base de la información existente al cierre del ejercicio sean susceptibles de dar lugar a las prestaciones citadas.

La provisión a dotar comprenderá el importe de las primas a reembolsar o prestaciones a satisfacer imputables al período o períodos del contrato ya transcurridos en el momento de cierre del ejercicio».

En sus alegaciones casacionales las partes cuestionan la interpretación de la normativa española aplicable a tenor de la jurisprudencia sentada por el TJUE.

La sentencia de dicho TJUE de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados unit-linked) (C-782/22, EU:C:2024:932), resulta del máximo interés. En ella, se contienen referencias a doctrina consolidada del propio Tribunal que permiten conocer su visión jurisprudencial.

Comenzaremos reproduciendo dos de sus apartados:

«28. De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (sentencias de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia*, C-641/17, EU:C:2019:960, apartado 48, y de 29 de julio de 2024, *Keva y otros*, C-39/23, EU:C:2024:648, apartado 40 y jurisprudencia citada).

31. Cuando un Estado miembro practica una retención en la fuente sobre los dividendos distribuidos por sociedades establecidas en ese Estado miembro, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, a efectos de determinar si una legislación de dicho Estado miembro es compatible con el artículo 63 TFUE, apartado 1,

corresponde al órgano jurisdiccional nacional de que se trate, único que puede examinar los hechos del litigio del que está conociendo, verificar si la aplicación de una retención en la fuente a los dividendos distribuidos a una sociedad no residente tiene como resultado, en definitiva, que dicha sociedad soporte una carga impositiva mayor, en el mismo Estado miembro, que la que soportan los residentes en relación con los mismos dividendos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, *Miljoen y otros*, C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608, apartado 48). »

También nos importan determinados apartados de la sentencia de 20 de junio de 2024, *Faurécia* (C-420/23, EU:C:2024:534) que sintetizan, en parte, la jurisprudencia sobre el marco jurídico originario de la libertad de circulación, concretamente, los siguientes:

«21 El artículo 63 TFUE, apartado 1, prohíbe con carácter general las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros. Las medidas prohibidas por esa disposición, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que puedan disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (sentencia de 27 de abril de 2023, *L Fund*, C-537/20, EU:C:2023:339, apartado 42 y jurisprudencia citada).

28.No obstante, con arreglo al artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), lo dispuesto en el artículo 63 TFUE se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital.

29 Según reiterada jurisprudencia, el artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), debe interpretarse en sentido estricto, ya que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales. Por lo tanto, este precepto no puede interpretarse en el sentido de que toda normativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en función del lugar en que residan o del Estado miembro en el que inviertan sus capitales es automáticamente compatible con el Tratado [sentencia de 16 de noviembre de 2023, *Autoridade Tributária e Aduaneira (Plusvalías por transmisión de participaciones)*, C-472/22, EU:C:2023:880, apartado 27 y jurisprudencia citada].

30 En efecto, las diferencias de trato permitidas por el artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), no deben constituir, de acuerdo con el apartado 3 del referido artículo, ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta. En consecuencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que tales diferencias de trato solo pueden autorizarse cuando afecten a situaciones que no sean objetivamente comparables o, en caso contrario, resulten justificadas por razones imperiosas de interés general [sentencia de 16 de noviembre de 2023, *Autoridade Tributária e Aduaneira (Plusvalías por transmisión de participaciones)*, C-472/22, EU:C:2023:880, apartado 28 y jurisprudencia citada]. »

Igualmente, resulte de interés los apartados 48 y 49 de la sentencia de 7 noviembre de 2024, *XX (Contratos denominados unit-linked)* (C-782/22, EU:C:2024:932), en tanto en cuanto se refirieren al requisito de la vinculación entre el gasto, pretendidamente deducible, y la actividad realizada. En ellos se declara:

«48 De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en lo que concierne a los gastos, como, por ejemplo, los gastos profesionales vinculados directamente a una actividad que ha generado rendimientos imposables en un Estado miembro, los residentes en este y los no residentes se encuentran en una situación comparable (véanse, en particular, las sentencias de 24 de febrero de 2015, *Grünwald*, C-559/13, EU:C:2015:109, apartado 29; de 8 de noviembre de 2012, *Comisión/Finlandia*, C-342/10, EU:C:2012:688, apartado 37; de 17 de septiembre de 2015, *Miljoen y otros*, C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608, apartado 57, y de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia*, C-641/17, EU:C:2019:960, apartado 74).

49 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, presentan un vínculo directo con la actividad considerada los gastos ocasionados por esta y necesarios por tanto para su ejercicio (sentencias de 24 de febrero de 2015, *Grünwald*, C-559/13, EU:C:2015:109, apartado 30 y jurisprudencia citada; de 13 de julio de 2016, *Brisal y KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, apartado 46, y de 6 de diciembre de 2018, *Montag*, C-480/17, EU:C:2018:987, apartado 33).»

En principio, las provisiones técnicas no parecen poder relacionarse con la percepción, en sí misma, de los dividendos. En términos semejantes a esta cuestión ya se ha planteado otra que ha sido abordada en la citada sentencia de 7 noviembre de 2024, *XX (Contratos denominados unit-linked)* (C-782/22, EU:C:2024:932), en relación con la posibilidad de deducir de su beneficio imponible relativo a los dividendos las cargas correspondientes a sus clientes en el marco de contratos de seguro "en unidades de cuenta".

En dicha sentencia, apartados 54 a 57, se declara:

«54 En efecto, en los apartados 55 y 81 de la sentencia de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia* (C-641/17, EU:C:2019:960), posterior a la sentencia de 17 de septiembre de 2015, *Miljoen y*

otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608), el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que un fondo de pensiones no residente que destine los dividendos percibidos a dotar provisiones por las pensiones que deberá abonar en el futuro, ya sea deliberadamente o de conformidad con la normativa vigente en su Estado de residencia, se encuentra en una situación comparable a la de un fondo de pensiones residente en relación con una normativa nacional en virtud de la cual, para calcular el impuesto sobre sociedades, la percepción de dividendos por ese fondo de pensiones residente da lugar a un incremento del resultado sujeto a tributación muy reducido, e incluso, en algunos casos, inexistente. Efectivamente, el Tribunal de Justicia señaló, en el mencionado apartado 55, que tal percepción conlleva un incremento proporcional de las provisiones técnicas y que únicamente se produce un incremento del resultado sujeto a tributación del fondo de pensiones residente cuando los rendimientos de las inversiones extracontables no se trasladen al crédito de los distintos contratos de este último fondo de pensiones.

55 En los apartados 79 y 80 de la sentencia de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia* (C-641/17, EU:C:2019:960), el Tribunal de Justicia consideró, en efecto, por una parte, que en el asunto que dio lugar a dicha sentencia existía una relación de causalidad entre la percepción de dividendos, el incremento de las provisiones matemáticas y de otras partidas del pasivo y la ausencia de incremento de la base imponible del fondo residente y, por otra parte, que tal normativa nacional, que permitía la exención total o prácticamente total de los dividendos abonados a los fondos de pensiones residentes, facilitaba así la acumulación de capitales de tales fondos, mientras que todos los fondos de pensiones están obligados, en principio, a invertir las primas de seguro en el mercado de capitales para generar ingresos en forma de dividendos que les permitan cumplir sus obligaciones futuras derivadas de los contratos de seguro.

56 Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que las obligaciones de los fondos de pensiones relativas a la inversión de las primas de seguro y a la afectación de los dividendos percibidos para provisionar las pensiones de jubilación pueden fundamentar la comparabilidad entre los fondos de pensiones residentes y no residentes a la luz de una normativa nacional que, mediante las modalidades de cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, permita eximir total o casi totalmente los dividendos percibidos por un fondo de pensiones residente, cuando exista una relación de causalidad entre la percepción de los dividendos y las cargas constituidas por dichas obligaciones y derivadas de la actividad de tales fondos.

57 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien una sociedad como XX no constituye un fondo de pensiones, la actividad de esta se caracteriza por el hecho de que dicha sociedad invierte, en particular en acciones en los Países Bajos, para cubrir sus compromisos frente a sus clientes en el marco de contratos en unidades de cuenta y que los rendimientos obtenidos de la inversión por dicha sociedad conllevan la correspondiente modificación del valor de sus compromisos frente a los clientes en virtud de los contratos mencionados.»

No cabe duda de la utilidad de las consideraciones que acabamos de reproducir. La intercambialidad de tales argumentos entre los fondos de pensiones y las compañías aseguradoras, a los presentes efectos, resulta viable.

La representación procesal de la Administración estatal no ha puntualizado qué objetivo persigue la deducción de las provisiones, pero está claro que se pretende, en última instancia, mantener la solvencia de las entidades. El único criterio de distinción entre residentes y no residentes en la normativa nacional se basa, realmente, en el lugar de residencia de la aseguradora.

La libre circulación de capitales se opone a una normativa nacional que tome en cuenta los rendimientos brutos de los no residentes sin deducir las provisiones técnicas, mientras que los residentes tributan por rendimientos netos previa deducción de los gastos de las provisiones técnicas.

El auto de admisión establece la relevancia casacional en torno al art. 24.6 del TRLIRNR. Ambas partes procesales parten del presupuesto de que los dividendos repartidos por una entidad residente en España se consideran rentas de actividades o explotaciones económicas obtenidas y, por ello, sometidas a tributación en España, en manos de las entidades no residentes que operen en nuestro país sin mediación de un establecimiento permanente. Dicho de otra forma, están sujetas ex artículo 15, siendo un supuesto de renta obtenida en España (actual artículo 13.1.f).

Las provisiones técnicas son gastos y como tales deducibles a efectos del impuesto de sociedades (art. 13 TRLIS y 14.7 LIS), siempre que hayan sido dotadas conforme a los criterios del citado Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en cuyo artículo 38 se recoge expresamente la provisión de participación en beneficios y para extornos. Dentro de este contexto normativo, cabe interpretar el artículo 24.6 del TRLIRNR y su aplicación a una provisión de semejante naturaleza.

La Abogacía del Estado considera que este tipo de provisiones técnicas en el ramo de seguros no equivalen al desarrollo de actividad aseguradora, más bien, a su juicio, estamos en presencia de una mera colocación de capital, sin embargo, ello se compadece mal con el actual sistema de seguros amparado por la normativa española, particularmente, el art. 29 ROSSP, reproducido anteriormente.

El funcionamiento general de las pólizas "unit linked" y las pólizas con participación en beneficios "no unit linked" resulta muy similar, a los efectos que ahora importan, dado que en ambos tipos existe un traslado económico de la rentabilidad producida por los dividendos a los tomadores de las pólizas, ya sea por soportar el tomador el riesgo económico de las inversiones (pólizas "unit linked"), o por haber acordado con los tomadores el traslado a ellos de una parte de la rentabilidad de los activos afectos a la póliza ("with profits").

Una provisión técnica de participación en beneficios, no cabe caracterizarla como ajena al proceso productivo del sector asegurador, donde la solvencia resulta capital. Así lo expresa la propia ley del sector, hoy vigente, Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. cuando manifiesta en su preámbulo:

«La Directiva Solvencia II supone un notable ejercicio de armonización que pretende facilitar el acceso y ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en la Unión Europea mediante la eliminación de las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros y, por tanto, el establecimiento de un marco legal dentro del cual las entidades aseguradoras y reaseguradoras puedan operar en un único mercado interior.

La Directiva Solvencia II articula una concepción de la solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras basada en tres pilares que se refuerzan mutuamente. El primero, constituido por reglas uniformes sobre requerimientos de capital determinados en función de los riesgos asumidos por las entidades, en consonancia con los desarrollos alcanzados en materia de gestión de riesgos y con la evolución reciente en otros sectores financieros. Se adopta así para el sector asegurador europeo un enfoque basado en el riesgo, mediante la introducción de normas específicas sobre el capital económico. El segundo de los pilares está integrado por un nuevo sistema de supervisión con el objetivo de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos por las entidades. El tercero se refiere a las exigencias de información y transparencia hacia el mercado sobre los aspectos clave de los riesgos asumidos por las entidades y su forma de gestión.

Adicionalmente a la introducción del nuevo sistema de solvencia basado en el riesgo y de los cambios que ello requiere en la forma de gestión de las entidades y en la actuación de las autoridades supervisoras, la Directiva Solvencia II efectúa una consolidación, por refundición, del resto del ordenamiento europeo en materia de seguros privados, salvo en lo referente al seguro de automóviles, incorporando los contenidos recogidos en las directivas que ya se habían transpuesto en su momento al Derecho español de seguros, como por ejemplo, la Directiva 2001/17/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros.

El esquema ha sido completado con los desarrollos normativos y la medidas de ejecución derivadas de la nueva estructura de supervisión diseñada en este campo en la Unión Europea por el establecimiento de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, mediante el Reglamento (CE) n.º 1094/2010, de 24 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión, que le atribuye importantes facultades de coordinación y decisorias en materia de supervisión y ordenación de seguros y reaseguros, logrando una mayor armonización reguladora y una mejor coordinación internacional e intersectorial.

Las disposiciones contenidas en esta Ley y en el reglamento que la desarrolle, resultado de la transposición de la Directiva Solvencia II, deben ser integradas con los desarrollos normativos y las medidas de ejecución dictadas por la Comisión Europea y por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) en un amplio conjunto de cuestiones como la valoración de activos y pasivos, provisiones técnicas, los fondos propios, el cálculo del capital de solvencia obligatorio, modelos internos, el capital mínimo obligatorio, las normas de inversión, el sistema de gobierno, el capital adicional, la información a efectos de supervisión, la transparencia de la autoridad supervisora, la solvencia de los grupos de entidades así como la determinación de la equivalencia de los regímenes de terceros países con las disposiciones de la Directiva Solvencia II. . »

Este enfoque se constata en la jurisprudencia del TJUE, destacando la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia* (C-641/17, EU:C:2019:960), de la que reproducimos tres apartados:

«48 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de

hacerlo en otros Estados (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, apartado 39, y de 22 de noviembre de 2018, Sofina y otros, C-575/17, EU:C:2018:943, apartado 23 y jurisprudencia citada)."

"80 Un normativa nacional que permite la exención total o prácticamente total de los dividendos abonados a los fondos de pensiones residentes facilita así la acumulación de capital de dichos fondos, mientras que, tal y como señaló el Gobierno alemán en la vista, todos los fondos de pensiones están obligados, en principio, a invertir las primas de seguro en el mercado de capitales para generar ingresos en forma de dividendos que les permitan cumplir sus obligaciones futuras derivadas de los contratos de seguro.

108 Pues bien, tal como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, la adquisición de participaciones por un fondo de pensiones y los dividendos que percibe a este respecto sirven principalmente para mantener los activos y garantizar las provisiones que ha constituido gracias a una mayor diversificación y a una mejor distribución del riesgo al objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de pago de pensiones de jubilación frente a sus afiliados. Así pues, esta adquisición de participaciones y estos dividendos son, en primer lugar, un medio empleado por los fondos de pensiones para poder cumplir sus compromisos en materia de pensiones y no un servicio que preste dichos afiliados.»

El art. 24.6 TRLIRNR no establece distinción alguna, habla literalmente de "gastos deducibles" y las provisiones técnicas lo son. El problema será, en consecuencia, determinar si las provisiones técnicas cuya deducción se pretende están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y si tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

Entendemos que cabe establecer un vínculo directo por cuanto la dotación de esta provisión tiene su causa en la obligación de asignar a los tomadores/beneficiarios parte de los beneficios obtenidos por la entidad aseguradora, ya sea de los beneficios financieros derivados de todas o una parte de sus inversiones o de los técnicos vinculados a la siniestralidad de toda o parte de la cartera de seguros. Mientras la primera modalidad es típica de los seguros de vida-ahorro, la segunda es habitual en los seguros de vida-riesgo u otros seguros personales (enfermedad, accidentes).

Esta conclusión está avalada en supuestos similares reconocidos por la jurisprudencia del TJUE:

En ese sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), de la que reproducimos dos apartados:

«74. En lo que atañe, en segundo lugar, a la alegación relativa a la diferente situación de los fondos de pensiones residentes y no residentes en cuanto a la posibilidad de que se tengan en cuenta las dotaciones a las provisiones para hacer frente a los compromisos en materia de pensiones como gastos profesionales, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que, en lo que concierne a los gastos, como, por ejemplo, los gastos profesionales vinculados directamente a una actividad que ha generado rendimientos imposables en un Estado miembro, los residentes en este y los no residentes se encuentran en una situación comparable (véanse, en particular, las sentencias de 31 de marzo de 2011, Schröder, C-450/09, EU:C:2011:198, apartado 40; de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia, C-342/10, EU:C:2012:688, apartado 37, y de 24 de febrero de 2015, Grünwald, C-559/13, EU:C:2015:109, apartado 29).

79 Así pues, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que existe una relación de causalidad entre la percepción de dividendos, el incremento de las provisiones matemáticas y de otras partidas del pasivo y la ausencia de incremento de la base imponible del fondo residente, en la medida en que los dividendos utilizados para las provisiones técnicas no incrementan el resultado sujeto a tributación del fondo de pensiones, extremo que fue confirmado por el Gobierno alemán en la vista. En efecto, según dicho Gobierno, una gran parte de los beneficios obtenidos a través de la inversión debe beneficiar al afiliado, lo que quiere decir que no pueden permanecer en el activo del fondo de pensiones y que los ingresos son la condición para el gasto en concepto de provisiones».

Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2016, Brisal y KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, conforme al Derecho nacional, qué gastos se pueden considerar directamente vinculados a la actividad en cuestión.

Precisamente, dentro de esa facultad de "apreciación" reconocida por la jurisprudencia comunitaria anteriormente transcrita, se encuentra la sentencia de instancia, quien procede a ponderar las circunstancias concurrentes tales como la correspondiente trazabilidad de las inversiones.

La recurrente realizó un esfuerzo probatorio que ha sido valorado por el tribunal de instancia ponderando de manera razonada los elementos probatorios puestos a su disposición.

No está demás, reproducir el apartado 49 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2016, *Brisal y KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, en la que se declara que

*«el mero hecho de que dicha prueba ofrezca mayor dificultad, no es motivo suficiente para que un Estado miembro deniegue de forma absoluta a los no residentes, sujetos pasivos por obligación real, una deducción que concede a los residentes, sujetos pasivos por obligación real, puesto que no puede excluirse a priori que un no residente pueda aportar los justificantes pertinentes que permitan a las autoridades tributarias del Estado miembro de tributación comprobar, de manera clara y precisa, la existencia y la naturaleza de los gastos profesionales cuya deducción se solicita (véanse, por analogía, las sentencias de 27 de enero de 2009, *Persche*, C-318/07, EU:C:2009:33, apartado 53, y de 26 de mayo de 2016, *Kohll y Kohll-Schlesser*, C-300/15, EU:C:2016:361, apartado 55).»*

En nuestra sentencia 13 de noviembre de 2019, rec. cas. 3023/2018, nos hicimos eco de que el TJUE ha señalado que *«las autoridades tributarias de un Estado miembro están facultadas para exigir al contribuyente las pruebas que consideren necesarias para apreciar si se cumplen los requisitos de una ventaja fiscal prevista por la legislación pertinente y, por consiguiente, si procede conceder o no dicha ventaja. No obstante, el ejercicio de dicha autonomía fiscal de los Estados miembros debe hacerse respetando las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión, especialmente las establecidas por las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, lo cual entraña que los potenciales beneficiarios no residentes no pueden estar sujetos a cargas administrativas excesivas que les impidan de forma efectiva beneficiarse del régimen fiscal de que se trata»*.

La evolución de la normativa española, la jurisprudencia del TJUE y de esta misma Sala, avalan una interpretación favorable a la pretensión de las aseguradoras desde el prisma de la libertad de circulación de capitales. En resumen, como consecuencia de la dotación de las provisiones técnicas, las empresas residentes en España se benefician de un crédito fiscal, solicitando la devolución de las retenciones en exceso sufridas. Posibilidad que debe ser también concedida a las entidades aseguradoras no residentes sin establecimiento permanente:

En nuestra sentencia de 5 de junio de 2018, rec. cas. 634/2017 declaramos que:

«la existencia de este trato discriminatorio, por contravenir el principio de libre circulación de capitales del artículo 63 TFUE, ha sido concluyentemente admitida por el legislador en la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria, que incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 24 de la Ley del IRNR, como argumenta la sentencia de instancia.

Como culminación de cuanto hemos expuesto, debemos afirmar que la vulneración del Derecho de la Unión Europea es aquí de doble signo: de un lado, en su aspecto material, porque las sociedades no residentes perceptoras de dividendos de empresas residentes son discriminatoriamente tratadas en relación con esas mismas empresas si fueran residentes, como consecuencia de que la base imponible del impuesto real se calcula en las primeras sobre el importe íntegro (artículos 23 de la Ley 41/1998 y 24 del Texto Refundido de 2004), sin posibilidad alguna de deducir los gastos o provisiones».

De la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2015, *Miljoen y otros* (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608), interesan los siguientes dos apartados:

*«64. Por consiguiente, es necesario distinguir las diferencias de trato permitidas en virtud del artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), de las discriminaciones prohibidas por el apartado 3 de ese mismo artículo. Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para que una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal pueda considerarse compatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, es preciso que la diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por razones imperiosas de interés general (véase la sentencia *Santander Asset Management SGII* y otros, C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, apartado 23 y jurisprudencia citada).*

*67. A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir del momento en residentes que un Estado miembro, de forma unilateral o por vía de convenios, somete al impuesto sobre la renta no sólo a los contribuyentes residentes sino también a los no residentes, por los dividendos que perciben de una sociedad residente, la situación de los mencionados contribuyentes no residentes se asemeja a la de los contribuyentes (véanse, en este sentido, las sentencias *Denkavit Internationaal* y *Denkavit France*, C-170/05, EU:C:2006:783, apartado 35; *Comisión/Italia*, C-540/07, EU:C:2009:717, apartado 52; *Comisión/España*, C-487/08, EU:C:2010:310, apartado 51; *Comisión/Alemania*, C-284/09, EU:C:2011:670, apartado 56, así como el auto *Tate & Lyle Investments*, C-384/11, EU:C:2012:463, apartado 31).»*

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia* (C-641/17, EU:C:2019:960) son destacables los siguientes apartados:

« 49 (...) el hecho de que un Estado miembro dispense a los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes un tratamiento menos favorable en comparación con el trato que se dispensa a los dividendos pagados a los fondos de pensiones residentes puede disuadir a las sociedades establecidas en un Estado miembro distinto de ese primer Estado miembro de invertir en él y, por consiguiente, constituye una restricción a la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 63 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de noviembre de 2012, *Comisión/Finlandia*, C-342/10, EU:C:2012:688, apartado 33; de 22 de noviembre de 2012, *Comisión/Alemania*, C-600/10, no publicada, EU:C:2012:737, apartado 15, y de 2 de junio de 2016, *Pensioenfond Metaal en Techniek*, C-252/14, EU:C:2016:402, apartado 28).

50 Constituye un tratamiento menos favorable la aplicación a los dividendos abonados a fondos de pensiones no residentes de una carga impositiva mayor que la que soportan los fondos de pensiones residentes en relación con los mismos dividendos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, *Miljoen y otros*, C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608, apartado 48). Lo mismo sucede cuando los dividendos pagados a los fondos de pensiones residentes se benefician de una exención total o parcial, mientras que los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes se someten a una retención en origen definitiva (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2012, *Comisión/Finlandia*, C-342/10, EU:C:2012:688, apartados 32 y 33).

51 Según se desprende de la resolución de remisión, en virtud de la normativa controvertida en el litigio principal, los fondos de pensiones están sujetos, por lo que respecta a los dividendos que se les distribuyen, a dos regímenes de tributación diferentes, cuya aplicación depende de su condición de residente en el territorio del Estado miembro de la sociedad que distribuye los dividendos.

56 De ello se deduce que, debido a esta deducción de las provisiones correspondientes a los dividendos percibidos de la base imponible para el cálculo del impuesto sobre sociedades, los dividendos percibidos por los fondos de pensiones residentes no incrementan dicha base imponible, o la incrementan de manera muy reducida.

63 Esta disposición debe interpretarse en sentido estricto, en la medida en que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales. Por lo tanto, no puede interpretarse en el sentido de que toda normativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en función del lugar en el que residen o del Estado miembro en el que invierten sus capitales es automáticamente compatible con el Tratado FUE. En efecto, la excepción establecida en el artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), está limitada, a su vez, por el artículo 65 TFUE, apartado 3, que prescribe que las disposiciones nacionales a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo «no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal como la define el artículo 63 [TFUE]» (sentencia de 10 de abril de 2014, *Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company*, C-190/12, EU:C:2014:249, apartados 55 y 56 y jurisprudencia citada).»

El reconocimiento del carácter deducible de la provisión de participación en beneficios y para extornos regulada en el art. 38 del ROSSP, se enmarca dentro del principio general de adaptación de la normativa española al acervo legislativo y jurisprudencial comunitario, e impone que las personas jurídicas no residentes, pero que residan en países de la UE, para determinar la base imponible de los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente puedan deducir los gastos conforme a lo previsto en la LIS, ciertamente, siempre que se acredite, que los mismos están relacionados directamente con los obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

Amparar un planteamiento como el auspiciado por la administración tributaria, supondría la introducción de distorsiones fiscales en directa colisión con la libre circulación de capitales del artículo 63 TFUE, esto es, consagrar un trato fiscal diferente por razón del lugar de residencia. No debemos olvidar, que el sistema asegurador ostenta un marco normativo armonizado (Directiva 2009/138/CE), y precisamente estamos ante un sector que precisa de ingente financiación, donde el flujo inversor entre los estados miembros resulta cada vez más indispensable para garantizar el sistema de coberturas y solvencia de la actividad aseguradora.

A mayor abundamiento, se insiste en que por la sentencia de instancia se estima la demanda puesto que se concluye que la entidad aseguradora ha realizado un esfuerzo probatorio serio y riguroso para acreditar la correlación del gasto que se pretende deducir con los ingresos obtenidos, extremo que soslaya de por entero en el escrito de interposición».

Por todo lo expuesto procede declarar no haber lugar al recurso de casación y confirmar la sentencia recurrida.

CUARTO.- Jurisprudencia que se establece.



Atendiendo a lo hasta aquí expuesto, y conforme ordena el artículo 93.1 LJCA, procede fijar la siguiente interpretación del artículo 24.6 Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con el artículo 38 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que sólo realicen en España inversiones de carácter financiero, por las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, pueden considerar, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 TRLIRNR, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) son fiscalmente deducibles para evitar una discriminación contraria a la libre circulación de capitales del artículo 63.1 TFUE, en tanto en cuanto ha de entenderse que dichos gastos están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

QUINTO.- Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

1º) Fijar los criterios interpretativos sentados en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia.

2º) No haber lugar al recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado en representación y defensa de la Administración General del Estado contra la sentencia dictada el 10 de mayo de 2023 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento ordinario núm. 701/2019, que se confirma.

3º) No hacer imposición de las costas procesales de esta casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.